

1500739-71.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... ouviu comentários que estivesse envolvido por tráfico. Soube pela esposa que ele já foi processado e condenado por tráfico.

O réu Disnei Souza Félix, em seu interrogatório, alega que realmente portava as drogas, mas não se destinavam ao tráfico, mas ao seu próprio consumo. Usa drogas há quatro ou cinco anos. Iria consumir as seis porções de crack, mas não de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500739-71.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500739-71.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2053626/2022 - 04º D.P. SANTOS, 23226612 - 04º D.P. SANTOS, 89/22/214 - 04º D.P. SANTOS, 2053626 - 04º D.P. SANTOS, 2053626/2022 - 4º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DISNEI SOUZA FELIX

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

DISNEI SOUZA FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 23 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas, na Praça Iguatemi Martins, em Santos, trazia consigo seis porções de crack, para entrega ao consumo de terceiros destinados ao comércio de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/110 e 133/135).

Devidamente notificado (fls. 117), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 120/121). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 137/139).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da prova de autoria e materialidade do delito. Quanto aos fatos, alega que merece dar credibilidade a palavra dos policiais militares, já que não parecia estar sob os efeitos de drogas na abordagem, assim como em outras abordagens anteriores. Já era conhecido nos meios policiais por ter retornado a se dedicar a esta atividade ilícita. Quanto à dosimetria da pena, pede o reconhecimento da reincidência específica.

A Defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para porte para o próprio consumo, a prova emprestada do laudo, reconhecendo a dependência química realizada em outro processo (0009677-22.2020.8.26.0562). Os policiais falam em menção de troca com outros dois agentes, sem que se possa precisar quem entregou a droga e quem entregou o dinheiro.

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia (fls. 89/90) que: "Em circunstâncias não esclarecidas, o denunciado obteve as drogas para vender. No dia da prisão, ele estava na via pública aguardando interessados na aquisição das drogas. Ele escondeu as porções da droga no interior de sua cueca. Sempre que surgia um interessado, o denunciado negociava o preço, recebia o dinheiro e entregava a droga. Policiais Militares observaram a conduta do denunciado e o abordaram. Ele foi revistado. Nesse momento, a droga foi encontrada sob suas roupas íntimas. A finalidade de vender as drogas ficou evidenciada pelas seguintes circunstâncias: 1) local onde o denunciado foi preso é usado por traficantes para a venda de drogas. 2) O denunciado não tinha em seu poder qualquer coisa que permitisse o consumo de drogas. 3) A droga apreendida estava dividida em seis porções individuais. 4) O denunciado confessou aos policiais que o prenderam, que iria vender as drogas encontradas em seu poder. 5) Dois policiais observaram o denunciado vendendo drogas. 6) O denunciado tinha R\$ 20,00, dinheiro obtido com a venda de drogas."

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo auto de constatação preliminar (fl. 11), pelo exame químico-toxicológico (fls. 133/135), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório. Corroborada com sincronia das narrativas das testemunhas, pelo estado de flagrância, bem como com o laudo químico-toxicológico.

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

Kaio Ferreira da Silva Kurashiki, Policial Militar, ouvido em juízo, esclareceu que estavam em patrulhamento de rotina quando adentraram na rua sete de setembro e avistaram 3 indivíduos em local conhecido como ponto de venda de drogas. Dois nitidamente eram moradores de rua, o outro, era o acusado, pessoa conhecida pelos seus antecedentes criminais e que já era de conhecimento da polícia que estava se dedicando ao tráfico de drogas. Ao avistar a presença da polícia, cada um tomou sentido diverso. Tiveram que optar por qual abordariam e o acusado foi escolhido. O acusado caminhou em da sete de setembro e nela foi abordado. Ele disse que nada tinha de irregular em sua posse, mas, em revista pessoal, localizaram seis pedras de crack em um elástico em sua cueca. Havia uma certa quantia em dinheiro. Ele confessou que estava traficando drogas. O acusado fez menção de troca com os dois moradores de rua. Ele jamais aparentou estar sob os efeitos de drogas em qualquer abordagem. O acusado não reagiu na oportunidade.

Fabrizio Viviani de Siqueira, Policial Militar, prestou depoimento no mesmo sentido. Visualizaram o acusado a uma distância de cinquenta a cem metros. Não conseguiram deter os outros dois indivíduos, pois precisaram optar porque caminharam para lados opostos. Conhecem o acusado em razão da sua vida pregressa e resolveram abordá-lo. Ele não é conhecido por ser usuário de drogas, nem mesmo estava com qualquer objeto destinado ao consumo das pedras em sua posse. Ele estava de bicicleta.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Thiago Alves de Moura, ouvido em juízo, viu o acusado sendo abordado pela polícia. Ele está sempre presente e o ajuda descarregando os caminhões de frutas que abastecem sua barraca na praça, local dos fatos. A esposa do acusado disse que ele estava fazendo uso abusivo de drogas e já havia conversado com ele. Ele nega o uso de crack, falava que faz uso ocasional de cocaína. Já o viu consumindo cocaína.

Whaislan Amaral dos Santos, ouvido em juízo, testemunhou que trabalha no mercado, o acusado mora próximo e está sempre nas redondezas. Ele faz uso abusivo de drogas. Ele corta seu cabelo. Ele estava com duas pessoas, que na hora da abordagem, cada qual foi para um lado. Ele ficou no meio. Chamaram a sua esposa. Já o viu usando cocaína atrás do seu caminhão uma vez. Ele usava pelas ruas. A esposa do acusado disse que ele já estava usando crack, mas não assumia. A esposa disse que já tentou sua internação, mas tudo o que sabe foi contado pela esposa do acusado. Jamais ouviu comentários que estivesse envolvido por tráfico. Soube pela esposa que ele já foi processado e condenado por tráfico.

O réu Disney Souza Félix, em seu interrogatório, alega que realmente portava as drogas, mas não se destinavam ao tráfico, mas ao seu próprio consumo. Usa drogas há quatro ou cinco anos. Iria consumir as seis porções de crack, mas não de uma única vez. Ia fazer uso na rua o meio. Não as seis de uma vez para sua esposa não desconfiar. Comprou a droga de um rapaz conhecido como "cabeça" e desde logo confessou aos policiais que a droga era para consumo, não para venda. Foi abordado com cerca de vinte reais (troco do cigarro que comprou). Já foi abordado anteriormente pelos mesmos policiais, sempre liberado por nada de ilícito ter em sua posse. Usa como mesclado na maconha e no cigarro, não usa direto. Tem um relacionamento há dez anos com sua esposa, mas ela não sabe de seu vício. Por diversas vezes tentou se abster da droga, mas com muita dificuldade pretende novamente parar e realizar tratamento. Se estivesse vendendo teria mais dinheiro em

sua posse. Faz uso quando brigam, pois prefere sair e ficar na rua, na sua "noia", sem ser violento com ela. No dia da abordagem estava de bicicleta, não percebeu a chegada da policia por estar em uma esquina. Não tem filhos com sua companheira. Tem um filho de 17 anos com sua ex-esposa, que faleceu. Era usuária de crack. Começou a utilizar drogas com a ex-companheira. Sua nova esposa está o ajudando a sair das drogas. Ela quando o conheceu, sabia que usava cocaína. Tenta esconder que usa crack também.

O acusado confessou que estava na posse da droga, e que estas estavam no interior de suas vestimentas, seis porções de crack.

Seja no tráfico, seja no uso, a conduta do agente de portar o entorpecente restou incontroversa e consumada, restando analisar, apenas, qual o intuito deste porte: o comércio a terceiros ou o consumo próprio.

A comprovação da elementar consumo pessoal exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não é circunstância de fácil constatação, devendo ser balizada pela própria situação fática.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, "A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE". (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

E ainda, "PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO É INDISPENSÁVEL A PROVA DO ATO DE COMÉRCIO, PODENDO SER ELE DEDUZIDO DE ELEMENTOS VARIADOS COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, O LOCAL DA INFRAÇÃO ETC." (TJRJ - Rel. Adolphino Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

No mesmo caminho trilha a jurisprudência: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA E CLORIDRATO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS DROGAS". (TJRJ - Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

É certo que a quantidade da droga é reduzida e até compatível com a condição de usuário, mas as testemunhas presenciaram o momento em que fazia menção de droga com dois moradores de rua, não estava na posse de qualquer objeto para consumir a droga naquele momento, assim como suas testemunhas e prova emprestada indicada pela defesa confirmam que consumia cocaína (fls. 35 do incidente de dependência química nº 0009677-22.2020.8.26.0562).

Em interrogatório confuso, o acusado pretende convencer que começou a usar drogas com a ex-companheira que faleceu pelo consumo abusivo de crack e que sua condição de dependente era de conhecimento da sua companheira desde que se conheceram, há mais de dez anos.

Desde então, tenta dela esconder o consumo abusivo de crack, mas depois afirma que apenas usa quando brigam.

Assim, a apreensão de quantidade significativa de entorpecente para consumo imediato não se amolda à postura de usuários da droga em tela, é meio de prova, um indício que, corroborado com outros elementos de prova como o local ser ponto de tráfico, ser conhecido nos meios policiais como traficante e a falta de ocupação

rentável que lhe garanta a aquisição de várias porções de droga para satisfazer o vício que tenta a todo custo esconder.

Tais elementos permitem a condenação do réu, porquanto permitem crer que seu destino era a entrega a consumo de terceiros.

Neste sentido segue a jurisprudência firme no sentido de que a quantidade do entorpecente, aliada a outros aspectos, é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes, ainda que dependente: "LEVANDO-SE EM CONTA A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADA, O VALOR E O ESCASSO PODER DE COMPRA DO ACUSADO, ALIANDO-SE AO FATO DE QUE LEVARA PARA O LOCAL DE SERVIÇO, TEM-SE QUE ESTÁ CORRETA A CLASSIFICAÇÃO NO ARTIGO 12 DA LEI 6368/76". (TJSP, Rel. Gentil Leite, RT 710/279).

Destaco, por fim, que a condição de usuário de entorpecente, ainda que reconhecida em exame de dependência química, não tem o condão de afastar a caracterização do tráfico de entorpecentes, notadamente quando é natural a comercialização de drogas pelo usuário para a manutenção do seu vício e que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta e de se autodeterminar.

Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da Lei 11343/06.

Demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da sua conduta, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade e variedade de droga, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Por força da reincidência específica (fls. 21/28), aumenta-se a pena na fração de um quarto, totalizando na reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não incide a causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois destinada ao réu seja primário e de bons antecedentes.

Em razão do caráter hediondo da conduta perpetrada e a reincidência específica, o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu DISNEI SOUZA FELIX, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A alteração levada a efeito no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, no tocante ao instituto da detração, é de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).

O merecimento do condenado integra os requisitos para sua promoção de regime, sendo crucial à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugere uma interpretação mais superficial do novo § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, dependendo do preenchimento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.

A reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do Código Penal, de tal sorte que a fixação de regime inicial ainda deve considerar obrigatoriamente, além da pena aplicada, se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.

Em razão do exposto, o desconto da pena cumprida pelo acusado deverá ser mesmo apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação, pois: "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória". (RHC 177 - RJ - 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89.)

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).

2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.

3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

P.I.C.

Santos, 24 de maio de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA